APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018464-74.2015.4.04.9999/SC

RELATORA	:	**Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA**
APELANTE	:	**ARI BATISTA**
ADVOGADO	:	**Fernando Cruzetta**
APELADO	:	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
ADVOGADO	:	**Procuradoria Regional da PFE-INSS**

D.E.

Publicado em 11/02/2016

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. **CUMULAÇÃO** DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR E APOSENTADORIA. RESP 1296673 REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI Nº 9528/97. CABIMENTO. TUTELA ESPECÍFICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Consoante definição do tema pelo STJ (REsp 1296673), a **cumulação** de auxílio suplementar por acidente do trabalho ou **auxílio-acidente** com aposentadoria só é possível se ambos (benefício acidentário e de aposentadoria) forem concedidos antes da vigência da Lei nº 9.528/97, que é o caso dos autos.

2. Tutela específica concedida, com cumprimento imediato do acórdão quanto ao restabelecimento do benefício postulado, tendo em vista a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 461 do CPC.

3. As prestações em atraso serão corrigidas pelos índices oficiais, desde o vencimento de cada parcela, ressalvada a prescrição quinquenal, e, segundo sinalizam as mais recentes decisões do STF, a partir de 30/06/2009, deve-se aplicar o critério de atualização estabelecido no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da lei 11.960/2009.

4. Este entendimento não obsta a que o juízo de execução observe, quando da liquidação e atualização das condenações impostas ao INSS, o que vier a ser decidido pelo STF em regime de repercussão geral (RE 870.947), bem como eventual regramento de transição que sobrevenha em sede de modulação de efeitos.

5. Os juros de mora são devidos a contar da citação, à razão de 1% ao mês (Súmula nº 204 do STJ e Súmula 75 desta Corte) e, desde 01/07/2009 (Lei nº 11.960/2009), passam a ser calculados com base na taxa de juros aplicáveis à caderneta de poupança (RESP 1.270.439), sem capitalização.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso, determinando o restabelecimento do benefício desde a indevida suspensão, o pagamento das parcelas em atraso e a implantação imediata do benefício, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2016.

Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA
Relatora

Documento eletrônico assinado por **Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **8068116v3** e, se solicitado, do código CRC **6940125D**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Vânia Hack de Almeida

Data e Hora: 27/01/2016 17:06

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018464-74.2015.4.04.9999/SC

RELATORA	**:**	**Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA**
APELANTE	**:**	**ARI BATISTA**
ADVOGADO	**:**	**Fernando Cruzetta**
APELADO	**:**	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
ADVOGADO	**:**	**Procuradoria Regional da PFE-INSS**

RELATÓRIO

Trata-se de ação objetivando o restabelecimento do auxílio-suplementar concedido em 01/04/1993, suspenso na via administrativa ante a impossibilidade de **cumulação** com a aposentadoria por invalidez concedida em 01/09/1995.

A sentença julgou a ação improcedente, deixando de condenar a parte autora em custas e honorários ante a isenção prevista no art. 129 da Lei nº 8213/91.

Apelou a parte autora, pugnando pelo restabelecimento do benefício suspenso. Alega, em síntese, que faz jus à **cumulação** pois ambos os benefícios foram concedidos antes da vigência da Lei nº 9528/97.

Foram oportunizadas as contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A questão colocada para julgamento já não comporta mais discussões, tendo em vista a definição do tema pelo STJ no julgamento do **REsp 1296673**, representativo de controvérsia, exarada nos seguintes termos:

"RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ***CUMULAÇÃO*** *DE BENEFÍCIOS.* ***AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA****. ART. 86, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 1.596-14/1997, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI 9.528/1997.* ***CRITÉRIO PARA RECEBIMENTO CONJUNTO****.* ***LESÃO INCAPACITANTE E APOSENTADORIA ANTERIORES À*** *PUBLICAÇÃO DA CITADA* ***MP (11.11.1997)****. DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DO MOMENTO DA LESÃO INCAPACITANTE. ART. 23 DA LEI 8.213/1991. CASO CONCRETO. INCAPACIDADE POSTERIOR AO MARCO LEGAL. CONCESSÃO DO* ***AUXÍLIO-ACIDENTE****. INVIABILIDADE.*

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com intuito de indeferir a concessão do benefício de ***auxílio-acidente****, pois a manifestação da lesão incapacitante ocorreu depois da alteração imposta pela Lei 9.528/1997 ao art. 86 da Lei de Benefícios, que vedou o recebimento conjunto do mencionado benefício com aposentadoria.*

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

3. ***A acumulação*** *do* ***auxílio-acidente*** *com proventos de aposentadoria* ***pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante****, ensejadora do direito ao* ***auxílio-acidente****,* ***e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração*** *do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991 ("§ 2º O* ***auxílio-acidente*** *será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua a****cumulação*** *com qualquer aposentadoria ; § 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria , observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do* ***auxílio-acidente****."),* ***promovida em 11.11.1997*** *pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997. No mesmo sentido: REsp 1.244.257/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.3.2012; AgRg no AREsp 163.986/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2012; AgRg no AREsp 154.978/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.6.2012; AgRg no REsp 1.316.746/MG, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 28.6.2012; AgRg no AREsp 69.465/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 6.6.2012; EREsp 487.925/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 12.2.2010; AgRg no AgRg no Ag 1375680/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Dje 19.10.2011; AREsp 188.784/SP, Rel. Ministro Humberto Martins (decisão monocrática), Segunda Turma, DJ 29.6.2012; AREsp 177.192/MG, Rel. Ministro Castro Meira (decisão monocrática), Segunda Turma, DJ 20.6.2012; EDcl no Ag 1.423.953/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki (decisão monocrática), Primeira Turma, DJ 26.6.2012; AREsp 124.087/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki (decisão monocrática), Primeira Turma, DJ 21.6.2012; AgRg no Ag 1.326.279/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 5.4.2011; REsp*
188.887/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (decisão monocrática), Primeira Turma, DJ 26.6.2012; AREsp 179.233/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão (decisão monocrática), Primeira Turma, DJ 13.8.2012 .

4. Para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão incapacitante em casos de doença profissional ou do trabalho, deve ser observada a definição do
art. 23 da Lei 8.213/1991, segundo a qual "considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro". Nesse sentido: REsp 537.105/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 17/5/2004, p. 299; AgRg no REsp 1.076.520/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 9/12/2008; AgRg no REsp 686.483/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 6/2/2006; (AR 3.535/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Terceira Seção, DJe 26/8/2008).

5. No caso concreto, a lesão incapacitante eclodiu após o marco legal fixado (11.11.1997), conforme assentado no acórdão recorrido (fl. 339/STJ), não sendo possível a concessão do ***auxílio-acidente*** *por ser inacumulável com a aposentadoria concedida e mantida desde 1994.*

6. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ."

REsp 1296673/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, dec. unânime em 22/08/2012, Dje de 03/09/2012) (sublinhei)

No caso concreto, considerando que o auxílio-suplementar foi concedido em 01/04/1993, e a aposentadoria por tempo de contribuição deferida em 01/09/1995, tem-se que ambos os benefícios são **anteriores à alteração legislativa**, de modo **a viabilizar a cumulação pretendida.**

Nesse sentido, precedente desta Turma:

*PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. AUXÍLIO-SUPLEMENTAR. **AUXÍLIO-ACIDENTE**. **1. É possível a cumulação de benefício de auxílio-suplementar com benefício de aposentadoria**. Decisões desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça neste sentido. Ambos os benefícios deferidos antes da Lei nº 9.528/97. **2.** Não é possível a integração do valor do benefício de auxílio-suplementar no cálculo do benefício de aposentadoria, considerando que já serão pagos de forma acumulada. Bis in idem. 3. Não é possível a majoração do percentual, sobre o salário-de-benefício do benefício de aposentadoria, pago a título de benefício de auxílio-suplementar para 50% a partir da entrada em vigor da Lei nº 9.032/95. Decisões desta Corte e do Supremo Tribunal Federal neste sentido.*
(APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5023757-43.2011.404.7100/RS, 6ª T., Rel. Des. Federal João Batista Pinto Silveira. Dec. un. em 03/10/2012)

Assim examinados os autos, acolho o recurso da parte autora e **reformo a sentença**, condenando o INSS a restabelecer o auxílio-suplementar desde a indevida suspensão (01/08/2007), e a pagar as parcelas em atraso, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora.

Tutela Específica

Considerando a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 461 do CPC e o fato de que, em princípio, a presente decisão não está sujeita a recurso com efeito suspensivo (TRF4, 3.ª Seção, Questão de Ordem na AC n.º 2002.71.00.050349-7/RS, Rel. para Acórdão Des. Federal Celso Kipper, julgado em 09/08/2007), o presente julgado deverá ser cumprido de imediato quanto à re-implantação do benefício postulado, com data de início do pagamento na data do presente julgamento. Prazo: 45 dias.

Correção Monetária e Juros de Mora

De início, esclareço que a correção monetária e os juros de mora, sendo consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício (AgRg no AREsp: 144069 SP 2012/0026285-1, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19-10-12). Assim, sequer há que se falar em *reformatio in pejus*.

A correção monetária, segundo o entendimento consolidado na 3ª Seção deste TRF4, incidirá a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelos índices oficiais e aceitos na jurisprudência, quais sejam:

- ORTN (10/64 a 02/86, Lei nº 4.257/64);
- OTN (03/86 a 01/89, Decreto-Lei nº 2.284/86);
- BTN (02/89 a 02/91, Lei nº 7.777/89);
- INPC (03/91 a 12/92, Lei nº 8.213/91);

- IRSM (01/93 a 02/94, Lei nº 8.542/92);
- URV (03 a 06/94, Lei nº 8.880/94);
- IPC-r (07/94 a 06/95, Lei nº 8.880/94);
- INPC (07/95 a 04/96, MP nº 1.053/95);
- IGP-DI (05/96 a 03/2006, art. 10 da Lei n.º 9.711/98, combinado com o art. 20, §§5º e 6.º, da Lei n.º 8.880/94);
- INPC (de 04/2006 a 29/06/2009, conforme o art. 31 da Lei n.º 10.741/03, combinado com a Lei n.º 11.430/06, precedida da MP n.º 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei n.º 8.213/91);
- TR (a partir de 30/06/2009, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009).

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, afastando a utilização da TR como fator de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, relativamente ao período entre a respectiva inscrição em precatório e o efetivo pagamento.

Em consequência dessa decisão, e tendo presente a sua ratio, a 3ª Seção desta Corte vinha adotando, para fins de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, a sistemática anterior à Lei nº 11.960/2009, o que significava, nos termos da legislação então vigente, apurar-se a correção monetária segundo a variação do INPC, salvo no período subsequente à inscrição em precatório, quando se determinava a utilização do IPCA-E.

Entretanto, a questão da constitucionalidade do uso da TR como índice de atualização das condenações judiciais da Fazenda Pública, no período antes da inscrição do débito em precatório, teve sua repercussão geral reconhecida no RE 870.947, e aguarda pronunciamento de mérito do STF. A relevância e a transcendência da matéria foram reconhecidas especialmente em razão das interpretações que vinham ocorrendo nas demais instâncias quanto à abrangência do julgamento nas ADIs 4.357 e 4.425.

Recentemente, em sucessivas reclamações, a Suprema Corte vem afirmando que no julgamento das ADIs em referência a questão constitucional decidida restringiu-se à inaplicabilidade da TR ao período de tramitação dos precatórios, de forma que a decisão de inconstitucionalidade por arrastamento foi limitada à pertinência lógica entre o art. 100, § 12, da CRFB e o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009. Em consequência, as reclamações vêm sendo acolhidas, assegurando-se que, ao menos até que sobrevenha decisão específica do STF, seja aplicada a legislação em referência na atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, salvo após inscrição em precatório. Os pronunciamentos sinalizam, inclusive, para eventual modulação de efeitos, acaso sobrevenha decisão mais ampla quanto à inconstitucionalidade do uso da TR para correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública (Rcl 19.050, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 21.147, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 19.095, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Em tais condições, com o objetivo de guardar coerência com os mais recentes posicionamentos do STF sobre o tema, e para prevenir a necessidade de futuro sobrestamento dos feitos apenas em razão dos consectários, a melhor solução a ser adotada, por ora, é orientar para aplicação do critério de atualização estabelecido no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da lei 11.960/2009.

Este entendimento não obsta a que o juízo de execução observe, quando da liquidação e atualização das condenações impostas ao INSS, o que vier a ser decidido pelo STF em regime de repercussão geral, bem como eventual regramento de transição que sobrevenha em sede de modulação de efeitos.

Quanto aos juros de mora, até 29-06-2009, apurados a contar da data da citação, devem ser fixados à taxa de 1% ao mês, com base no art. 3º do Decreto-Lei n. 2.322/87, aplicável analogicamente aos benefícios pagos com atraso, tendo em vista o seu caráter eminentemente alimentar, consoante firme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e na Súmula 75 desta Corte.

A partir de então, deve haver incidência dos juros, uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, nos termos estabelecidos no art. 1º-F, da lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009. Os juros devem ser calculados sem capitalização, tendo em vista que o dispositivo determina que os índices devem ser aplicados "uma única vez" e porque a capitalização, no direito brasileiro, pressupõe expressa autorização legal (STJ, 5ª Turma, AgRg no AgRg no Ag 1211604/SP, Rel. Min. Laurita Vaz).

Quanto ao ponto, esta Corte já vinha entendendo que no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 não houvera pronunciamento de inconstitucionalidade sobre o critério de incidência dos juros de mora previsto na legislação em referência.

Esta interpretação foi, agora, chancelada, pois no exame do recurso extraordinário 870.947, o STF reconheceu repercussão geral não apenas à questão constitucional pertinente ao regime de atualização monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, mas também à controvérsia pertinente aos juros de mora incidentes.

Em tendo havido a citação já sob a vigência das novas normas, inaplicáveis as disposições do Decreto-lei 2.322/87, incidindo apenas os juros da caderneta de poupança, sem capitalização.

Honorários Advocatícios

Os honorários advocatícios são devidos pelo INSS no percentual de 10% sobre as parcelas vencidas até a decisão judicial concessória do benefício previdenciário pleiteado, conforme definidos nas Súmulas nº 76 do TRF4 e nº 111 do STJ.

Custas Processuais

Custas pela metade, devidas pela autarquia previdenciária, nos termos do art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual de Santa Catarina nº 156/97.

Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, não há necessidade de o julgador mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua decisão, tampouco os citados pelas partes, pois o enfrentamento da matéria através do julgamento feito pelo Tribunal

justifica o conhecimento de eventual recurso pelos Tribunais Superiores (STJ, EREsp nº 155.621-SP, Corte Especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13-09-99).

ANTE O EXPOSTO, voto por dar provimento ao recurso, determinando o restabelecimento do benefício desde a indevida suspensão, o pagamento das parcelas em atraso e a implantação imediata do benefício.

É O VOTO.

Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA
Relatora

Documento eletrônico assinado por **Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **8068115v2** e, se solicitado, do código CRC **E2171D7A**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Vânia Hack de Almeida
Data e Hora:	27/01/2016 17:06

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 27/01/2016

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018464-74.2015.4.04.9999/SC
ORIGEM: SC 00028405120138240044

RELATOR	:	Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA
PRESIDENTE	:	Desembargadora Federal Vânia Hack de Almeida
PROCURADOR	:	Procurador Regional da República Cláudio Dutra Fontella
APELANTE	:	ARI BATISTA
ADVOGADO	:	Fernando Cruzetta
APELADO	:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO	:	Procuradoria Regional da PFE-INSS

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 27/01/2016, na seqüência 669, disponibilizada no DE de 15/01/2016, da qual foi intimado(a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 6ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO, DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A INDEVIDA SUSPENSÃO, O PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO E A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

RELATOR ACÓRDÃO	:	Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA
VOTANTE(S)	:	Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA
	:	Juiz Federal OSNI CARDOSO FILHO
	:	Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA

Gilberto Flores do Nascimento
Diretor de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Gilberto Flores do Nascimento, Diretor de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **8099402v1** e, se solicitado, do código CRC **9711E1F2**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Gilberto Flores do Nascimento
Data e Hora:	28/01/2016 12:25